

1500247-41.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500247-41.2021.8.26.0269 - Controle 2021/000625

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCOPIO

Data da Audiência:

22/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Gilmar Santiago Rodrigues Procopio. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Ana Cláudia Vieira Carlos Leme arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Sérgio Filipe Albuquerque Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado pela prática de crime de porte de entorpecentes, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas pela prova colhida sob o pálio do contraditório. Com efeito, ouvidos na polícia e em juízo, os policiais confirmaram a abordagem e apreensão do entorpecente em posse do réu, que então alegou que se destinava ao seu próprio consumo. Interrogado, o acusado admitiu a posse do entorpecente e que se destinava ao seu próprio consumo. Dessa forma, resulta clarividente a prática do crime previsto no estatuto de prevenção e repressão às drogas, de modo que sua responsabilização se faz de rigor. Portanto, demonstradas autoria inequívoca e

materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz. O acusado foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. A ação penal, no entanto, não merece prosperar, pelas razões que seguem. 1- Do art. 28 da Lei de Drogas. Atipicidade da conduta. Inconstitucionalidade e inconveniência do art. 28 da Lei n. 11343/06. Precedentes. O tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 viola o direito à intimidade e o princípio da lesividade penal, padecendo de inconstitucionalidade. O inciso X do artigo 5º da Constituição da República assevera que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Assim, por meio deste dispositivo legal, a Constituição atribuiu ao indivíduo liberdade para escolher seu modo de vida. Não é legítima a norma penal, em um Estado Democrático de Direito, que pretenda tutelar a saúde ou integridade de uma pessoa contra sua própria vontade e interesse, sendo tal pretensão intangível ao poder estatal. Só é admissível a intervenção do Direito Penal quando houver lesão concreta ou real, transcendental, grave ou significativa e intolerável ao bem jurídico tutelado. Logo, sob a ótica do princípio da lesividade, não existe crime sem lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bem como não há crime quando a conduta viola apenas bens jurídicos pessoais, por força da ausência da transcendência da ofensa. Por este motivo, não é admissível a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, pois tal conduta não ultrapassa o âmbito privado do agente. Assim, reside a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas em dois pontos. Primeiro, porque o comportamento previsto no tipo não transcende a esfera pessoal do usuário, violando, assim, sua intimidade (vida íntima) e privacidade (autonomia privada) e ferindo, dessa forma, o princípio da transcendência. Em segundo lugar, a conduta prevista no tipo viola o princípio da lesividade, porque não há lesão ou perigo concreto a bem jurídico. Foi reconhecida a repercussão geral sobre o tema “tipicidade penal do porte de droga para consumo pessoal” no julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário n. 635.659. O julgamento do recurso ainda não foi concluído, mas o Min. Gilmar Mendes, relator, declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas sem redução de texto, votou pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, mas mantendo as sanções previstas no dispositivo legal, conferindo-lhes natureza exclusivamente administrativa. Pelo mundo, as experiências descriminalizadoras são positivas. Os países que adotaram a descriminalização do consumo de entorpecentes observaram uma redução no índice de consumo e é chegado, portanto, o momento de o Brasil adequar-se ao paradigma contemporâneo para o tratamento do tema. Assim, considerando a evidente inconstitucionalidade do dispositivo, o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP. 2- Da dosimetria da pena. Na hipótese de eventual desfecho condenatório da ação penal em apreço, requer seja aplicada a pena de advertência, prevista no inciso I do art. 28 da Lei de Drogas, dando-se a pena por cumprida. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não há razões neste momento para a decretação pela custódia cautelar. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCÓPIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 31 de dezembro de 2020, por volta da 00 h e 30 min, na Av. José de Almeida Carvalho, próximo ao número 377, Vila Aparecida, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para uso próprio, duas porções de “crack”, com peso de 0,24 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida, fls. 73, e o Réu citado por edital, fls. 76, não compareceu em juízo e não constituiu Defensor, assim o processo foi suspenso, fls. 82. Após, foi citado pessoalmente, fls. 98, e respondeu a acusação por intermédio da Defensoria Pública, fls. 102/103. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, o Réu foi interrogado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu; por outro lado, a Defesa insistiu na absolvição. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A ação penal é procedente. Às fls. 09/10 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual

consta: duas pedras de "crack", com peso se 0,4 gramas; uma sacola plástica; quatro mochilas; um mini maçarico e uma tesoura. O Laudo de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 9.320/2021, fls. 19/21, constatou a presença do princípio ativo COCAÍNA. Ana Cláudia Vieira Carlos Leme, policial militar, testemunha, disse que estavam em patrulhamento, quando se depararam com o Réu; fizeram a abordagem e encontraram as porções de entorpecentes. Gilmar Santiago Rodrigues Procópio, Réu, ao ser interrogado, disse que possuía as pedras de "crack" para uso. Confrontando-se a prova coligida infere-se que o Réu foi visto quando trazia consigo 02 porções de entorpecentes. Pela quantidade apreendida e ausentes observações de venda, verifica-se a destinação pessoal. Confirmada a suficiência das provas, não merece prosperar a tese da atipicidade da conduta, pois, apesar de ter se operado a despenalização da conduta de porte de drogas para consumo próprio, não ocorreu a sua descriminalização. O artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 não prevê em seu preceito secundário qualquer pena privativa de liberdade, mas prevê sanções de outra natureza, logo houve mera despenalização, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem: "I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.ª Turma, DJe. 27.04.2007). "[...] A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011). Destarte, é impositiva a condenação por incidir o Réu no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para condenar GILMAR SANTIAGO RODRIGUES PROCÓPIO, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. O Réu respondeu em liberdade a este processo e, tendo em vista a pena aplicada, poderá recorrer nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio

virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 22 de setembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA